

1500297-29.2022.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... obra. Alegou ser usuário e que nunca traficou. Não conhecia os policiais e acredita que os mesmos sentiram o cheiro de drogas em suas vestes. Disse que foi acusado por tráfico anteriormente por ter sido pego na "biqueira". Foi preso quando estava em liberdade provisória. Às reperguntas do Ministério Público disse que não houve denúncia anônima pois não estava vendendo drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, ., Varadouro - CEP 11600-000, Fone: (12) 3892-3111, Sao Sebastiao-SP - E-mail: saosebacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital:

1500297-29.2022.8.26.0626 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLAN MARTINS MOY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucia Fernandes Paiva

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 59/60, no dia no dia 08 de junho de 2022, por volta das 18:02 horas, na Avenida Engenheiro Remo Corrêa Silva, nº 1750, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, WALLAN MARTINS MOY, qualificado à fl. 08, trazia consigo para fins de tráfico de drogas, 13 tabletes de Cannabis sativa L., substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 102g (cento e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 10 e auto de exibição e apreensão de substância entorpecente de fls. 11.

Em razão destes fatos, o réu WALLAN MARTINS MOY, qualificado à fl. 08, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 70/71) e o réu citado (fl. 78). Sobreveio resposta à acusação (fl. 83/84), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 85/88).

Houve a realização de audiência de instrução (fls. 108/111), com a oitiva de duas testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia, em razão do conjunto probatório, em especial o depoimento dos guardas municipais, ouvidos em juízo.

Ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06,

por ser o réu usuário de drogas. Subsidiariamente em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase de dosimetria; requereu na terceira fase a aplicação da atenuante do privilégio, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena observando o quantum de pena fixada. Requereu, ainda, o direito de acusado recorrer em liberdade, a isenção da pena de multa e a aplicação da detração penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência (fls. 02/04), laudo de constatação (fl. 10), relatório policial (fls. 51/53), laudo químico toxicológico (fls. 98/100) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre o réu.

O guarda civil metropolitano Diego de Oliveira Vieira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que um dia antes recebeu uma denúncia de um munícipe informando que um rapaz estava vendendo drogas em um isopor, indicando horários, mas não acharam o réu. No dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando abordaram o réu e acharam drogas na roupa do réu e entre os doces. O réu vendia drogas no centro comercial e na rua da praia. Às reperguntas da Defesa disse nunca havia abordado o réu anteriormente, chegando ao mesmo por meio de denúncia. Foi seu parceiro quem fez a abordagem, mas não houve testemunhas.

O guarda civil metropolitano Roberto Alves Drygala, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que recebeu denúncia de morador do bairro, indicando pessoa de cor branca com uma bicicleta e uma caixa de isopor estaria exercendo a atividade de traficância, indicando o nome que a caixa de isopor continha o logo da marca "Apple". No dia seguinte, em patrulhamento avistaram o autor, que foi reconhecido por conta das características físicas e pelo logo da marca "Apple" na caixa de isopor, sendo que até o nome era o mesmo informado pelo denunciante. Em busca pessoal, foi encontrado drogas na blusa e na caixa de isopor, que também continha pipoca doce. Às reperguntas da Defesa disse foi a primeira abordagem do réu. Tinha pessoas passando pelo local, mas ninguém parou para presenciar. Foi o autor da abordagem, mas não se lembra de detalhes.

Não foram arroladas testemunhas defensivas.

O réu Wallan Martins Moy, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que foi na "biqueira" e comprou drogas para consumo em grande quantidade, uma vez que não tinha pequena quantidade disponível para venda e que não queria retornar mais de uma vez com medo de se prejudicar. Acredita ter comprado dez pedaços, por volta de 100 gramas. Deixou a droga dentro da jaqueta e não no isopor. Após, foi para a praia trabalhar como vendedor ambulante, considerando que foi demitido de uma obra. Alegou ser usuário e que nunca traficou. Não conhecia os policiais e acredita que os mesmos sentiram o cheiro de drogas em suas vestes. Disse que foi acusado por tráfico anteriormente por ter sido pego na "biqueira". Foi preso quando estava em liberdade provisória. Às reperguntas do Ministério Público disse que não houve denúncia anônima pois não estava vendendo drogas. Acredita que foi denunciado na biqueira, uma vez que pegou todas drogas do local. Disse que as drogas estavam na jaqueta e não na caixa de isopor que continha os doces.

Pois bem.

Os guardas municipais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os mesmos tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos funcionários públicos ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas.

Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho dos guardas municipais, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O réu, em juízo, admitiu a propriedade dos entorpecentes (13 tabletes de Cannabis sativa L., substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 102g (cento e dois gramas)) que os policiais encontraram sob sua posse, entretanto, afirmou que seria destinado ao seu consumo pessoal e que, por ser usuário contumaz, adquiriu grande quantidade a fim de evitar reiteradas idas à "biqueira".

Percebe-se, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

O acusado não comprovou qualquer atividade lícita, alega que as drogas eram destinadas ao seu consumo e, novamente, não comprovou - por qualquer meio de prova - seu suposto vício em drogas.

Como se não bastasse, verifica-se que na data dos fatos o réu se encontrava gozando de liberdade provisória em um processo que responde por tráfico de drogas (fl. 38), denotando que se posto em liberdade nesta data há sérios riscos de reiteração de delitiva.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Dessa forma, o exercício de autodefesa processual restou isolado, incongruente e inverossímil se confrontada com o restante das provas constantes dos autos, pelo que merece ser afastado.

Anoto que a quantidade e a natureza da drogas apreendida (13 tabletes de Cannabis sativa L., substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 102g (cento e dois gramas)), o local onde se deram os fatos e o depoimento coeso e harmonioso dos policiais, evidenciam que eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o consumo próprio.

Ressalte-se que os policiais disseram que localizaram os entorpecentes nas vestes e na caixa de isopor de propriedade do réu. Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de

acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSP Ap.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação do acusado como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, vez que o réu é portador de bons antecedentes (fls. 66/67 e 68/69) e as circunstâncias do delito não desbordam do ordinário. Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade entorpecente apreendido (peso bruto aproximado de 102g (cento e dois gramas)) na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário e tem a seu favor a atenuante da menoridade relativa descrita no artigo 65, I, do Código Penal. Contudo, a pena já está no mínimo legal e não pode ficar aquém desse patamar nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Ainda que o réu esteja sendo processado nos autos nº 1500324-32.2022.8.26.0587 (fl. 68), deve prevalecer o entendimento de que condenações criminais sem trânsito não afastam a causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado. No julgamento do HC 175.466, a Ministra Cármen Lúcia decidiu que o tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional". A tese teve origem em posição adotada pelo ministro Gilmar Mendes (HC 151.431).

Diminuo a pena na fração mínima de 1/2, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, com elevado potencial de causar dependência química aos seus usuários (STJ, AgRg no RESp 1.902.218, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j.

09.03.2021), resultando assim a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Como o réu é primário e sem antecedentes e como a pena não superou quatro anos e as circunstâncias judiciais não justificam punição maior, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da detenção (artigo 33, § 2º, 'c', Código Penal).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, dada a quantidade de pena global aplicada e a primariedade, sopesando-se ainda as circunstâncias em concreto já estampadas na fixação das penas, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução.

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado WALLAN MARTINS MOY, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos, e o regime de pena imposto é incompatível com a segregação cautelar. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

O réu não apresentou prova da origem lícita dos valores com ele apreendido, razão pela qual decreto sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto aos valores e às drogas.

Cumpra-se.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA